

1500066-43.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... delitos.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500066-43.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500066-43.2022.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026099/2022 - DEL.POL.TARUMA, 22705384 - DEL.POL.TARUMA, 44/22/126 - DEL.POL.TARUMA, 2026099 - DEL.POL.TARUMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO DA SILVA CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, com supedâneo nos arts. 128, I, da CRFB, e 24, caput, do CPP, ajuizou ação penal contra RODOLFO DA SILVA CAMARGO, já qualificado, em razão da perpetração, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, assim narrado na denúncia:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta de 16h00min, na rua Matrichan, n. 184, Vila das Árvores, na cidade de Tarumã, nesta Comarca de Assis, RODOLFO DA SILVA CAMARGO, qualificado à fl. 15, tinha em depósito e guardava, sem autorização legal, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 11 porções de Tetrahydrocannabinol (maconha), pesando aproximadamente 133,54g (cento e trinta e três gramas e cinquenta e quatro miligramas), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), fotografias (fls. 34/35), laudo de constatação (fls.

36/38) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 104/106), sendo certo que tais substâncias causam dependência psíquica.

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que o denunciado realizava tráfico de drogas e inclusive realizava a divulgação em redes sociais e até mesmo passava cartão de crédito. Então, se deslocaram até a residência de RODOLFO, que estava na via pública e, assim que avistou a viatura policial, tentou adentrar na casa, mas foi abordado.

Durante a revista pessoal, foi questionado sobre a venda de drogas, tendo o denunciado confessado e indicado onde estavam os entorpecentes. Assim, encontraram debaixo do sofá da casa as drogas, assim como uma balança de precisão, duas caixas de 'seda', dois rolos de papel filme e a quantia em dinheiro no valor de R\$100,00 (cem reais), além de uma máquina do mercado pago.

Diante dos fatos, o denunciado foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Não há dúvida que a conduta do indiciado subsume-se ao tipo penal do artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06, pela informação recebida, pela condição de sua prisão, pela quantidade de drogas apreendida, pela forma de acondicionamento das substâncias e dinheiro, bem como pela balança de precisão e a faca em que detectada a presença de maconha (laudos de fls. 102/107) e a máquina de passar cartão bancário, localizados com o denunciado, tudo a confirmar as informações anteriormente recebidas, assim como pelas mensagens encontradas em seu aparelho de celular apreendido, conforme laudo pericial de fls. 136/142."

Observado o rito especial da Lei 11.343/2006, após a apresentação de defesa prévia (fls. 179-182), a denúncia foi recebida a 13 de junho de 2022, oportunidade em que se designou audiência de instrução e julgamento (fls. 290-291).

Regularmente citado (fl. 314), o acusado foi interrogado, bem como foram inquiridas as testemunhas arroladas.

O Ministério Público, em suas alegações finais orais, pediu, em sinopse, a condenação do imputado nos termos da denúncia.

Doutro lado, a defesa do réu, também em alegações finais orais, requestou a absolvição, com arrimo no art. 386 do CPP.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há questões pendentes.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais, passo, incontinenti, ao exame do mérito.

A materialidade do fato delituoso foi comprovada com o auto de prisão em flagrante (fls. 3-4), o boletim de ocorrência (fls. 5-8), o auto de exibição e apreensão (fls. 9-10), as fotografias coloridas (fls. 34-37), o laudo toxicológico definitivo (fls. 38-40), o laudo pericial (fls. 124-126) e os depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e judicial.

A autoria também é líquida e certa.

A testemunha Anderson Luiz Ferreira de Souza, policial militar, ao longo da instrução, relatou que, a 28 de janeiro de 2022, patrulhava no Município de Tarumã-

SP, quando recebeu “denúncia anônima” dando conta de que o acusado, numa casa de esquina, traficava drogas. Foi-lhe informado, inclusive, que o denunciado publicava anúncios nas redes sociais. Dirigiu-se à vivenda. Visualizou-o defronte do portão. Ele tentou ingressar no imóvel, sem sucesso, porém, pois abordado na parte da frente. Nada foi encontrado nas buscas pessoais, exceto um aparelho de telefone celular. Questionado, ele confessou a prática delitiva. Na sala, debaixo duma almofada, descortinou onze porções de maconha; na cozinha, havia uma balança de precisão, R\$ 100,00 (cem reais), além de plástico amudadamente utilizado para embalar drogas. O réu acrescentou que fornecia seda a seus clientes.

A testemunha Simone da Silva Belasco, policial militar, em solo judicial, narrou que: naquele dia, recebeu “denúncia anônima” de que o acusado traficava; deparou com ele defronte da residência; ele tentou entrar, mas mesmo assim foi abordado; em conversas, ele confessou o crime; em cima da mesa, localizou dinheiro e balança de precisão; ele apontou, inclusive, droga no sofá; não demonstrava estar sob efeito de substância estupefaciente.

A testemunha Clóvis Soares Pereira, em Juízo, negou saber se o denunciado trafica substâncias ilícitas; doutro lado, notou que ele é usuário de maconha; o imputado labuta a vender salgados.

O testigo Claudinei Ribeiro de Macedo, durante o processo, respondeu que o réu trabalha vendendo salgados; não sabe se ele fazia uso de substâncias entorpecentes.

O réu RODOLFO DA SILVA CAMARGO, em seu interrogatório judicial, negou a perpetração do piáculo a ele irrogado na denúncia. Redarguiu que terminava uma encomenda de salgados, eis que foi surpreendido por agentes da autoridade policial na sua cozinha. Indagou-lhes acerca do mandado, que responderam negativamente. Deu-lhes as drogas. Eles penetraram no imóvel sem sua autorização. Não conhece os agentes da autoridade policial, tampouco tem algo contra eles. Relativamente à balança de precisão, redarguiu que a usava para pesar alimentos, pois vendia salgados. Quanto aos papéis de plástico, usava-os para embalar os víveres. No que pertine às sedas apreendidas, a despeito de grande quantidade, usava-as. No respeitante às mensagens, não soube explicar por que pessoas lhe perguntaram se possuía “chá” para vender.

Esses foram os elementos de informação e de prova produzidos. Diante deles, indubitável se mostra a autoria delitiva, de modo a se revelar como o único desate possível o condenatório.

Como se viu acima, o acusado negou a perpetração do crime de tráfico ilícito de narcóticos. As suas assertivas, contudo, estão em total descompasso com os elementos aos autos amealhados, não tendo sido corroboradas; além de inverossímeis, foram cabalmente rechaçadas.

Doutra banda, da leitura dos depoimentos dos agentes da autoridade policial extrai-se relevante prova da autoria da infração imputada ao denunciado.

Isso porque, em duas oportunidades, isto é, perante o Delegado de Polícia e diante deste Juízo, eles atestaram, com minudência, as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, confirmando que o imputado tinha consigo as drogas e os apetrechos utilizados pelo tráfico arrolados na denúncia.

Não há indícios de parcialidade nos depoimentos. Questionado em audiência, o réu negou conhecê-los. Ora, muito improvável que eles tenham, gratuitamente, mentido para imputar falsamente um crime a um inocente.

A jurisprudência é farta no sentido do aceite das palavras de policiais militares que participaram das investigações ou efetuaram a prisão, seguindo, como exemplo,

excertos de decisões do STJ e do STF, respectivamente:

“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva processual.” (STJ, HC 241.728/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 14/03/2013).

“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.” (STF, HC 87.662/PE, Rel. Ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 05/09/2006).

Merecem credibilidade, dessarte, as declarações dos agentes da autoridade policial.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais militares, responsáveis pela diligência que culminou com a prisão do denunciado e apreensão dos entorpecentes, afirmaram haver “denúncias anônimas” que davam conta da prática de tráfico de drogas no local da diligência.

As “delações apócrifas”, devem ser vistas com ressalvas; cautela; no entanto, urge reconhecer que, em casos como o destes autos, tal instrumento tem auxiliado sobremaneira a atividade policial no combate à criminalidade.

O Poder Público, quando provocado pela “delação anônima”, pode (e deve) adotar medidas informais destinadas a apurar, previamente, com prudência e discricção, a possível ocorrência de delitos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS INDICATIVAS DO ENVOLVIMENTO DA RÉ COM O CRIME ORGANIZADO. FRAÇÃO MÉDIA APLICADA E JUSTIFICADA PELA DOUTA MAGISTRADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO COM DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO DINHEIRO APREENDIDO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO QUE COMPORTA REFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CORRELAÇÃO DO DINHEIRO ENCONTRADO E SUA ORIGEM ILÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação se comprovadas a autoria e a materialidade do delito. 2. 'A denúncia anônima não é em si ilegal nem invalida o feito, se a prisão e posterior processamento de ação penal contra os agentes decorre da realização de diligências em que se constata a efetiva prática do crime resultando, inclusive, em prisão em flagrante.' (Rel. Lillian Apelação Criminal nº 767.768-7 Romero; 3ª C. Crim., Ap. Crim. nº 279.103-7, DJ 01/04/05). 3. 'O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal' (STF HC n. 73.518- 5/SP). 4. Muito embora o Pleno do Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade da vedação à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos aos condenados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, no presente caso não é possível tal substituição, visto que a condenada não preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal. 5. A decisão que meramente decreta o perdimento de valores, nos termos do artigo 63, da Lei nº

11.343/06, sem apontar os elementos de convicção que o levaram a crer que a quantia tinha origem ilícita é abusiva, e exige reforma." (TJPR - 3ª C.Criminal - AC 0767768-7 - Colorado - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Jefferson Alberto Johnsson - Unânime - J. 02.06.2011).

Incontestável, portanto, a validade da "denúncia anônima" como mais um fundamento para a condenação do imputado, já que confirmada posteriormente pela apreensão das drogas.

Sublinhe-se que, para a configuração do crime inscrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, não terá importância a quantidade de substâncias estupefacientes apreendidas, se a finalidade de venda estiver comprovada.

In casu, o que já foi dito, aliado à quantidade de droga apreendida (onze porções de maconha), a forma de acondicionamento da droga, a importância de dinheiro encontrada, a balança de precisão, apetrecho amiudadamente utilizado para embalagem de estupefacientes e as sedas são outros importantes elementos a caracterizarem a traficância.

Sobre o tema, segue entendimento o entendimento pátrio, representado pela ementa do aresto do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 33 DA LEI 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS E INSOFIMÁVEIS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADO A DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CARACTERÍSTICAS DO CASO CONCRETO APONTANDO PARA A TRAFICÂNCIA. PENA E REGIME PRISIONAL ESCORREITOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO HABITUAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para configuração do crime de tráfico de drogas não é necessário que se presencie a venda (no presente caso a polícia presenciou a venda), bastando que se tipifique qualquer um dos 18 verbos previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Assim, a quantidade e espécie de droga, a forma como estava acondicionada, o local e as denúncias anônimas e circunstâncias em que foi preso em flagrante a apelante, demonstram nitidamente a feição do tráfico de drogas. A redução do § 4.º do artigo 33, da Lei 11.343/2006 teria como 'caráter teleológico objetivado pelo legislador' beneficiar o 'marinheiro de primeira viagem', como o usuário ou dependente que 'não resiste a um comando do traficante para vender, e com isso obter o necessário em droga para o sustento de seu vício' (FREITAS, Jayme Walmer de. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1476, julho de 2007). Circunstância não atestada no caso em debate, pois o apelante exercia livremente o tráfico, estando a ele ligado há algum tempo" (TJPR - 3ª C. Criminal - AC 0705937-6 - Telêmaco Borba - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Jefferson Alberto Johnsson - Unânime - J. 11.11.2010).

Quanto à balança de precisão, não obstante o réu tenha dito que a usava para alimentos, a verdade é que nela pesava drogas. E isso pode ser encontrado no laudo de fls. 124-126, que atestou haver resquícios de maconha nela. Além disso, as fotografias de fls. 141 e 142 mostram balança idêntica àquela apreendida na posse do acusado.

Relativamente às sedas, foram apreendidas em grande quantidade. O imputado respondeu que as comprava para usar, pois fumava muito. Doutro lado, os agentes da autoridade policial, em seus depoimentos, disseram que o réu, durante a diligência, ao confessar, acrescentou que fornecia sedas aos seus consumidores. Tais assertivas, conjugadas à vultosa quantidade de seda encontrada, demonstram que, deveras, ele também as fornecia, o que é mais um elemento a indicar a traficância.

Convém sublinhar as conversas oriundas da devassa do aparelho de telefone celular.

Algumas pessoas indagaram-no se ele possuía “chá” para vender. A resposta é não. Questionado em Juízo pelo Promotor de Justiça, não soube dizer por que alguém o perguntaria disso.

Ora, trata-se de mais um indicativo de traficância. Sim, porque, frequentemente, para ver-se livre de eventual imputação o traficante utiliza outros verbetes para se referir à droga. E chá, como se sabe, é sinônimo de maconha. Não haveria motivos para que pessoas estranhas saíssem a indagá-lo se vendia drogas, exceto se realmente o fizesse, obviamente.

Ainda, cabe esclarecer que, para a caracterização do tráfico de drogas, é prescindível a efetiva comercialização das substâncias tóxicas, bastando que o agente as detenha com aquela finalidade. E, no caso dos autos, restou amplamente demonstrado que o réu tinha consigo e mantinha em depósito as drogas apreendidas, visando entregar a terceiros.

Nesse sentido:

“Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Pretendida a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais se revestem de fé pública e, assim, merecem credibilidade como elementos de convicção – Apreendidas, em estado de flagrância, drogas de natureza diversificada e em quantidade elevada, indicativa de tráfico – Circunstâncias da prisão, destacadas pela prova testemunhal, que reforçam o “animus” de traficância – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o efetivo ato de mercancia, se outras circunstâncias denotam o dolo de traficar – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Sob o prisma legal, traficante não é apenas aquele que comercializa drogas – Uma vez demonstrado o desígnio de cometer o tráfico, a condição de usuário não afasta a responsabilização do agente pelo delito do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 – Dosimetria – Correta e proporcional a exasperação da pena-base, em face da variedade e da quantidade de drogas (art. 42 da Lei 11.343/06) – Descabida a benesse do “tráfico privilegiado”, por força da reincidência – Sem amparo, igualmente, o pleito de aplicação da minorante do artigo 46 da Lei 11.343/06, porquanto inexistente, nos autos, qualquer comprovação de que o apelante não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento – Regime inicial fechado atraído pela reincidência – Pena de multa que não comporta modificação – Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1500309-90.2020.8.26.0633; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021).

Por fim, o réu não conseguiu demonstrar nem indícios de suas alegações.

3. DOSIMETRIA DA PENA

Considerando as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e, com preponderância, o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, passo à individualização das penas impostas ao acusado.

3.1. Circunstâncias judiciais

Na primeira fase, reputo que a personalidade do agente é desviada da moral média. Merece censura porque mentiu em Juízo, imputado graves irregularidades a agentes da autoridade pública, em versão totalmente dissociada da realidade. Além de mentir, ele tentou convencer este Juízo de que os policiais violaram o seu domicílio e alteraram a verdade dos fatos, porquanto jamais confessou. Essa atitude demonstra distorção de caráter e a ausência de senso moral pelo réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e maliciosamente induzir em

erro o julgador, afrontando a dignidade da Justiça.

Esclareço que a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica e o CPP apenas chancelam que a pessoa não seja compelida a produzir prova contra si e que permaneça em silêncio no interrogatório. Não há previsão legal que autorize a mentira e a obstrução da justiça. Isso porque é princípio basilar que quando não existem dúvidas sobre o texto legal (expressões unívocas) inexistente espaço para que o intérprete busque alterar o seu sentido. A utilização da hermenêutica só se legitima diante da presença de dúvida sobre o conteúdo do texto das normas. Quando não há possibilidade de diversidade de interpretações ao texto legal não se pode buscar alterar o seu sentido a pretexto de hermenêutica, sob pena de se usurpar a competência do Poder Legislativo. Certamente não foi a intenção do legislador outorgar licença para mentir, visando injusta absolvição.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que, ainda que o interrogatório seja um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para realização da justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu e para a sociedade. É forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeça e deslealdade processual, expondo a risco a justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): “Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

Ainda sobre o tema, vale citar parte do artigo "A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", do Promotor de Justiça Dr. Cleber Pereira Defina:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"

(http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68, acesso em 14 de setembro de 2022, destaquei).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*). Contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade. Ao revés, deve o julgador, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

A consideração da mentira na ocasião da dosimetria da sentença tem sido aceita pela jurisprudência, conforme voto da lavra do ilustre Desembargador José Raul Gavião de Almeida: "...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade" (TJSP, Apelação 00771651-20.2015, 6ª Câmara de Direito Criminal, j.30/11/2017 destaquei).

Tal elemento também foi destacado no voto do eminente Desembargador Tetsuzo Namba: "...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP, Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/11/2019, destaquei).

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, o exmo. Des. Zorzi Rocha anotou que: "se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 3.10.2019, destaquei).

Com muita razão a ilustre Desembargadora Ivana David manteve aumento de pena por este motivo: "É escorregadia a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, "nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo", demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em

sua vida. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 10/12/19, destaquei).

No mesmo sentido cito outros julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelação Criminal 0011154-90.2017.8.26.0625; Rel. Des.: Machado de Andrade; 6ª Câmara de Direito Criminal; j.: 25/04/2022; Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, rel. Des. Roberto Porto, 8ª Câmara de Direito Criminal, j.29/11/2018; Apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, rel. Des. Walter da Silva, 14ª Câmara Criminal, j.28/03/2019.

Assim, ponderadas as circunstâncias judiciais, que não são totalmente desfavoráveis, salvo quanto à personalidade do agente, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/5 (um quinto), fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 6 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

3.2. Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes.

Inexistem, igualmente, circunstâncias agravantes.

Permanece, então, a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

3.3. Minorantes e majorantes

Do que consta destes autos, o condenado é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, motivo pelo qual aplico a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na sua fração mínima. Sim, porque ainda que não seja vultosa a quantidade de drogas apreendida, ela é considerável. E isso não pode deixar de ser avaliado no caso concreto. Reduzo, então, a reprimenda em 1/3 (um terço) e fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, além de 400 (quatrocentos) dias-multa.

3.4. Do valor do dia-multa

Do que consta dos autos, o condenado não possui bens de valor, tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

3.5. Do regime inicial para cumprimento da pena

Em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena imposta, a primariedade do condenado e a falta de várias circunstâncias judiciais negativas, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

3.6. Detração

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de

evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados, destarte, a primeira progressão de regime.

Entretanto, o regime fixado foi o aberto, de sorte que deixo de proceder à detração.

3.7. Da substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena

Verifico que o condenado não é reincidente; as circunstâncias judiciais não lhe são totalmente desfavoráveis; o montante de pena aplicado é igual a 4 (quatro) anos; o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça. Com fundamento artigos 43, 44, caput, incisos I, II e III, bem como o seu § 2º, 45, § 1º, e 46, todos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam:

- i. prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, cumprindo uma hora por dia de condenação, junto a entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução;
- ii. prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos nacionais vigentes, a ser recolhida em favor de entidade beneficente a ser determinada pelo Juízo da Execução.

Embora cediço, a despeito de a Lei 11.343/2006 (artigo 33, §4º) obstruir a conversão de pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256, de relatoria do ministro Ayres Britto, entendeu pela inconstitucionalidade da vedação. Por sua vez, o Senado Federal, empregando a competência estatuída no artigo 52, inciso X, da Constituição da República Federativa do Brasil, editou a Resolução n. 5/2012, suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do aludido parágrafo.

Incabível o sursis, diante da substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (artigo 77, inciso III, do Código Penal).

4. RECURSO E ENCARCERAMENTO

Considerando a quantidade de pena imposta, o regime inicial fixado e a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, não se encontram presentes, é óbvio, os requisitos e pressupostos necessários à custódia cautelar.

5. OS BENS APREENDIDOS

Ao proferir a sentença, o Juiz deve deliberar sobre o perdimento de produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias (artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/2006).

Os valores apreendidos na posse do réu, como se viu algures, foram por ele obtidos através do tráfico ilícito de entorpecentes.

E, segundo o artigo 243, parágrafo único, da Constituição, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Passando assim as coisas, declaro o perdimento do numerário em favor da União, com fundamento nos artigos 243, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil, 62 e 63, ambos da Lei 11.343/2006, e 91, inciso II, do Código Penal.

O mesmo se dará quanto aos demais bens apreendidos.

6. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na exordial e: i. condeno o réu RODOLFO DA SILVA CAMARGO nas iras do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; ii. fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, estes com valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em regime inicial aberto; iii. substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consoante acima explicado; iv. declaro a perda, em favor da União, dos objetos apreendidos.

Após o trânsito em julgado, e independentemente de nova determinação: i. comunique-se ao Juízo Eleitoral, conforme o artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; ii. comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD, em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo; iii. expeça-se guia de recolhimento; iv. arquivem-se estes autos.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Assis, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA